

1026391-53.2022.8.26.0050

Classe: Habeas Corpus Criminal

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Marcela Dias De Abreu Pinto Coelho

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: DIPO 3 - Seção 3.1.1

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... signatários assinaram a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em 20 de dezembro de 1988, em Viena, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 162, de 14 de junho de 1991, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 154, de 26 de junho de 1991. Muito embora neste documento não seja dado enfoque expresso à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

DIPO 3 - Seção 3.1.1

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1026391-53.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1026391-53.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Habeas Corpus Criminal - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Impetrante:

Carlos Augusto Burza

Paciente (Passivo):

Luiz Diego Burza

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Dias De Abreu Pinto Coelho

Vistos.

Trata-se de ação de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Carlos Augusto Burza, em favor de LUIZ DIEGO BURZA, contra ato iminente a ser praticado pelas Autoridades Policiais, representadas nas pessoas do Delegado Geral de Polícia Civil de São Paulo e do Comandante Geral da Polícia Militar de São Paulo, visando à obtenção de salvo-conduto a fim de que as autoridades policiais encarregadas sejam impedidas de realizar a prisão em flagrante do paciente pelo cultivo, uso, porte e produção artesanal da Cannabis para fins exclusivamente medicinais.

Segundo consta na inicial (fls. 01/17), emendada às fls. 79, em síntese, em 2005, o paciente de Luiz Diego Burza teria sofrido um traumatismo craniano, com hemorragia cerebral, do qual teria resultado dor de cabeça crônica, razão pela qual passou a fazer uso de medicamentos analgésicos, a exemplo da "novalgina", sem muito

resultado.

Em 2007, o paciente mudou-se para a Califórnia, nos Estados Unidos, e passou a fazer uso, por recomendação médica, de cannabis em diversas formas (em óleo, em flor ou em tinturas) a serem compradas nas “dispensaries” (farmácias especializadas na comercialização de produtos derivados de cannabis). Com essa recomendação, era possível, inclusive, cultivar legalmente plantas de cannabis.

Aponta, ainda, que o uso da cannabis trouxe excelentes resultados, com substancial melhora no quadro clínico ao paciente, o que o teria impulsionado a realizar um curso junto à Oaksterdam University, que segundo alega, é a primeira instituição de ensino referente ao estudo completo de tudo que envolve a planta, desde seu cultivo até a extração.

Tendo retornado ao Brasil, recebeu recomendação médica para o uso de produtos derivados de cannabis, e por consequência, realizou o trâmite de autorização de importação da ANVISA dos produtos Pangaia CBD e MGC Pharma (CBD/THC), com validade, respectivamente, até 12/09/2024 e 12/07/2024 (fls. 27/30). Contudo, alega o impetrante, que a compra dos medicamentos importados é de alto custo, e que o prazo de entrega é longo, sendo a administração caseira do extrato de Cannabis Sativa a partir do cultivo das plantas mais econômica.

Assim, o impetrante requer, em sede de liminar, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, para assegurar que os agentes policiais do Estado de São Paulo se abstenham de atentar contra a sua liberdade de locomoção, em razão do autocultivo em casa dos vegetais para tratamento com Cannabis medicinal, bem como fiquem impedidos de apreender as plantas utilizadas no respectivo tratamento. No mérito, requer a concessão da ordem com a confirmação da liminar. Juntou documentos (fls. 18/56).

A petição inicial foi emendada à fl. 79 e recebida à fl. 80.

O Ministério Público apresentou parecer às fls. 83/84.

A decisão de fls. 86/89 deferiu a liminar pleiteada.

As Autoridades ditas coatoras prestaram informações às fls. 104/105 e 125/129.

O Ministério Público ofertou parecer pela denegação da ordem às fls. 113/116.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

No mérito, confirmo a liminar para conceder a ordem do presente Habeas Corpus preventivo consistente na expedição de salvo-conduto para evitar ameaça de violência ou coação ilegal por autoridade policial (artigo 660, §4º, do Código de Processo Penal).

In casu, o paciente sofre de dores de cabeça crônicas em razão de sequelas de um traumatismo craniano, com hemorragia cerebral, sofrido em 2005, tendo apresentado resposta insatisfatória ao tratamento com fármacos conservadores.

Após fazer uso de medicamentos analgésicos, a exemplo da “novalgina”, sem muito resultado, foi prescrito, por médicos especialistas norte-americano e brasileiro, o uso de medicamento à base de Cannabis Sativa, com substancial melhora no quadro clínico.

Nesse passo, saliente-se que o direito à saúde se sobrepõe a eventuais entraves do Estado em delimitar parâmetros para autorização de cultivo da planta que origina a droga maconha e desenvolver fiscalização periódica, como informado superficialmente pelas autoridades coatoras, bem como pelo Ministério Público.

Ante a ausência de regulamentação federal a respeito de plantio, cultura e colheita de vegetais de que possam ser extraídas drogas, para fins medicinais ou científicos, em território brasileiro, em observância ao artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, cabe ao Poder Judiciário conceder a ordem na tutela dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana.

Vale frisar que o paciente ostenta autorização de importação da ANVISA dos produtos Pangaia CBD e MGC Pharma (CBD/THC), com validade, respectivamente, até 12/09/2024 e 12/07/2024 (fls. 27/30), e ajuizou a presente ação pelo custo elevado de adquirir o produto medicinal, bem como pela demora no recebimento deste em caso de importação.

Ademais, considerando a crise econômica atual, sobretudo com o desemprego e a desvalorização da moeda nacional, e a imprescindibilidade do uso do óleo extraído

da planta Cannabis Sativa L para a saúde do paciente, é de rigor a confirmação da liminar.

Por fim, é sabido que já há diversas decisões proferidas no Brasil que asseguram a inúmeros cidadãos a fruição de direito semelhante ao pleiteado nesta ação de habeas corpus, conforme se depreende, a título exemplificativo, dos recentes julgados proferidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Habeas corpus preventivo impetrado em primeira instância - Cultivo de cannabis sativa para fins medicinais - Pretensão de expedição de salvo-conduto a fim de possibilitar que os recorrentes possam cultivar cannabis sativa, em sua residência, com o objetivo de obter o óleo terapêutico utilizado para o tratamento da sua filha, tratamento este indicado por médico devidamente registrado no CRM - Relatório indicando a eficácia da substância no caso concreto, havendo efetiva melhora no quadro clínico - Previsão legal quanto à possibilidade de cultivo de vegetais dos quais se possam ser extraídas drogas, desde que com finalidade medicinal ou científica, a teor do artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06 - Matéria que ainda carece de regulamentação - Proteção do direito à saúde, que deve se sobrepor aos interesses secundários do Estado - Conduta que não se reveste de culpabilidade, de modo que não resta configurado ilícito penal - Inexigibilidade de conduta diversa - Segredo de Justiça que se faz necessário - Questão envolvendo interesse de incapaz, além de representar risco à segurança pública, caso seja publicamente conhecida - Recurso provido, a fim de conceder salvo-conduto aos recorrentes, para que possam cultivar, em seu domicílio, a planta cannabis sativa, com finalidade única e exclusiva de produzir o óleo terapêutico utilizado para o tratamento da sua filha, nos termos de sua prescrição médica, mediante o cumprimento das condições especificadas nesta instância." (TJSP - Recurso em Sentido Estrito 1016472-58.2020.8.26.0196; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020) (Grifei).

""Habeas corpus" preventivo. Cultivo domiciliar de "Cannabis sativa" para o tratamento medicinal dos filhos, portadores de Transtorno do Espectro Autista. Laudos médicos. Prescrição de óleo rico em canadibiol. Resultados promissores. 2. Substância regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Pendente regulamentação do cultivo domiciliar da planta para fins medicinais. Regulamentação, há mais de cinco anos, pelo Conselho Federal de Medicina. 3. Artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06. Possibilidade de plantio, cultura e colheita de vegetais dos quais possam ser produzidas drogas, desde que com fins medicinais ou científicos. 4. Circunstâncias concretas do caso que indicam que o comportamento não configura ilícito penal, por falta de culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa enquanto fator supra legal de exclusão da culpabilidade. Ordem concedida." (TJSP - Habeas Corpus Criminal 2053254-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020) (Grifei).

Nesse ponto, vale ressaltar que, recentemente, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de Habeas Corpus nº 1016472-58.2020.8.26.0196, o Desembargador Relator, Excelentíssimo Doutor Ricardo Sale Júnior, discorreu amplamente sobre as normativas legais concernentes à possibilidade de extração artesanal do óleo da Cannabis para fins medicinais, sendo de suma importância a transcrição a seguir:

"Ocorre que, muito embora a possibilidade de autorização do plantio e cultivo de cannabis esteja prevista no ordenamento jurídico pátrio há mais de 40 (quarenta) anos, a questão segue sem regulamentação ou norma específica.

A partir da análise das normas acima transcritas, fica claro que a finalidade incriminadora da Lei nº 11.343/06 não busca albergar o cultivo de plantas, das quais possam se extrair drogas, com fim medicinal, na medida em que o bem jurídico tutelado pela respectiva normal penal visa à proteção da saúde pública, não tendo

como escopo, portanto, prejudicar, de qualquer forma, a efetivação do direito fundamental à saúde, garantido pela Constituição Federal, como também não era esta a finalidade da revogada Lei de Drogas nº 6.368/76.

Em verdade, tais normas evidenciam que, há mais de 40 (quarenta) anos mais precisamente desde 22 de novembro de 1976, data em que a Lei nº 6.368/76 entrou em vigor, 30 (trinta) dias após sua publicação em 22 de outubro de 1976, nos termos do seu artigo 47 a União encontra-se em mora para regulamentar tal prática, sendo certo que a ANVISA, enquanto o órgão regulador competente para registrar produtos, substâncias e serviços que podem afetar a saúde da população, detém a competência para complementar a norma penal em branco, por meio de Resolução, porém não o fez até o presente momento.

Não se desconhece, por certo, que a proposta de plantio de cannabis sativa para fins medicinais foi rejeitada pela Diretoria Colegiada da ANVISA, a qual, após consulta pública, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 327, de 09 de dezembro de 2019, autorizou apenas a fabricação e a importação de produtos de Cannabis, excluindo, assim, a regulamentação do plantio do respectivo vegetal. Ocorre que, a partir da leitura do parágrafo único do artigo 2ª, da Lei nº 11.343/06, conclui-se que o cultivo das plantas ali mencionadas, para fins exclusivamente médicos, não consiste em mera possibilidade do Poder Público, devendo ser interpretada como verdadeiro dever estatal de efetivação do direito fundamental à saúde daqueles que necessitam do referido tratamento, ante a ineficiência do tratamento médico convencional.

Este verdadeiro poder-dever do Estado para regulamentar a questão ora em debate pode ser extraído, também, a partir das Convenções Internacionais sobre drogas, das quais o País é signatário.

A Organização das Nações Unidas (ONU) possui três Convenções sobre tóxicos, que constituem, até hoje, os principais documentos internacionais de referências, servindo de baliza aos Estados-membros no momento de elaborar suas legislações internas sobre o tema.

A primeira delas é a Convenção Única sobre Entorpecentes, assinada em Nova Iorque em 30 de março de 1961, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 05, 07 de abril de 1964, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 54.216, de 27 de agosto de 1964, na qual se percebe o reconhecimento da comunidade internacional a respeito do perigo das substâncias psicoativas, considerando a toxicomania um mal grave para o indivíduo e um perigo social e econômico para a humanidade. Em que pese tal preocupação, nota-se, também, o reconhecimento do uso médico de substâncias entorpecentes, quando indispensáveis para o alívio da dor e sofrimento, prevendo medidas adequadas para que possa garantir a disponibilidade de sua utilização para tal desiderato medicinal³.

Registre-se, ainda, que o Diploma em questão, em seu artigo 49, inciso II, alínea "f", estabelece que "o uso da Cannabis para fins que não sejam médicos ou científicos deverá cessar o mais cedo possível, e, de qualquer, maneira, dentro de 25 anos a contar da entrada em vigor da presente Convenção", o que deixa claro, portanto, a finalidade de não proibição da utilização da referida substância quando utilizada com finalidade terapêutica.

Posteriormente, assinou-se a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas (Viena - 21 de fevereiro de 1971), aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 90, de 05 de dezembro de 1972, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 79.388, de 14 de março de 1977, na qual a comunidade internacional reconheceu que o uso de substâncias psicotrópicas para fins médicos e científicos é indispensável, sendo que a disponibilidade de tais substâncias com essa finalidade não deve ser indevidamente restringida, trazendo, no bojo do seu artigo 5º, regras acerca da limitação do uso para fins médicos e científicos.

Por fim, os países signatários assinaram a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em 20 de dezembro de 1988, em Viena, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 162, de 14 de junho de 1991, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 154, de 26 de junho de 1991. Muito embora neste documento não seja dado enfoque expresso à questão do uso de substâncias ilícitas para fins medicinais, terapêuticos ou científicos, é

certo que, analisando-se o seu teor, constata-se o emprego reiterado da expressão "ilícito", a partir do qual se infere que, além das substâncias ilícitas, é possível haver, também, algumas empregadas com finalidade lícita (aqui compreendido o uso medicinal e terapêutico), alinhando-se, assim, aos anteriores diplomas internacionais sobre a matéria.

Dessa forma, à luz das normas internacionais sobre o tema, criadas justamente com a finalidade de repercutir no ordenamento jurídico interno dos países signatários, desponta nítido o entendimento de que o cultivo, bem como a utilização de substância extraída da cannabis sativa, com fim unicamente medicinal ou terapêutico, não pode ser inserida, de nenhuma forma, dentro das regras que buscam coibir, internacional ou nacionalmente, o tráfico ilícito de entorpecentes. Da mesma forma, a referida conduta também não pode ser equiparada àquela inserta no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ou mesmo no artigo 33, caput, da referida legislação, eis que representaria legítimo descompasso com a própria finalidade da norma, mormente quando ela própria traz, em seu bojo, a possibilidade de se autorizar o plantio, cultura e colheita de cannabis, além de outros vegetais, exclusivamente para fins medicinais ou científicos."

Dessa forma, conclui-se que é possível, excepcionalmente, para o caso específico e individual do paciente, a autorização para cultivo de Cannabis Sativa com finalidade estritamente medicinal, permitindo-se a extração artesanal das substâncias necessárias ao tratamento medicinal.

Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM neste Habeas Corpus impetrado pelo advogado Carlos Augusto Burza, em favor de LUIZ DIEGO BURZA, para confirmar a decisão liminar de fls. 86/89, e determinar a EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO, permitindo o cultivo da planta Cannabis Sativa L na residência do paciente, com o fim exclusivo de uso do extrato da referida planta para o tratamento medicinal, em quantidade compatível com a prescrição médica, restando impedidas as autoridades policiais do Estado de São Paulo, representadas nas pessoas do Delegado Geral de Polícia Civil de São Paulo e do Comandante Geral da Polícia Militar de São Paulo, de proceder à sua prisão ou detenção pela produção da referida espécie vegetal, bem como de apreendê-la.

Consigno que fica o paciente autorizado, pelo prazo de 06 (seis) meses, a semear e cultivar a planta apenas e tão-somente em seu domicílio e na quantidade compatível com os parâmetros estabelecidos na prescrição médica.

A presente decisão tem caráter personalíssimo. Desse modo, o paciente LUIZ DIEGO BURZA, será o único beneficiado com o extrato produzido, não podendo ser concedido a terceiros.

Deverá o paciente informar imediatamente este Juízo, em caso de eventual e futura desnecessidade da medida para o tratamento, não sendo a presente decisão uma autorização sem prazo. Assim, fixo o prazo de seis meses para que o paciente, nestes autos, apresente relatório médico atualizado que contenha a expressa indicação da necessidade de continuação do tratamento, a fim de obter a renovação do salvo-conduto.

Comunique-se à Autoridade Policial responsável pela circunscrição do local de residência do paciente, até para que tal cultivo possa ser fiscalizado pelas autoridades policiais.

Decorrido o prazo para interposição de recursos voluntários sem provocação das partes, submeta-se a presente sentença ao reexame necessário, remetendo-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do disposto no artigo 574, inciso I do Código de Processo Penal.

Sem custas e despesas processuais, a teor do artigo 5º, inciso LXXVII da Constituição Federal.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Intimem-se.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA